

1500766-45.2020.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marina Freire

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - TRÁFICO DE DROGAS - CRIME PERMANENTE - NULIDADE INEXISTENTE - ASSOCIAÇÃO CRIMINAL - ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO. Em razão do caráter permanente do delito de tráfico de drogas, o flagrante é possível a qualquer momento, não constituindo ilegalidade o ingresso de policiais na residência do suspeito, mesmo sem mandado de busca e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500766-45.2020.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

EDUARDO DA SILVA SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Marina Freire

Vistos.

EDUARDO DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 8 de agosto de 2020, no período da manhã, na Alameda Demóstenes, nº 9-30, Parque Jaraguá, nesta cidade e Comarca de Bauru, tinha em depósito 2,19 g de entorpecente conhecido como crack, divididos em 17 porções, e 8,81 g de entorpecente conhecido como maconha, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Oferecida a denúncia (fls. 1/2), por decisão de fls. 80/81 foi determinada a notificação do réu.

O réu foi notificado (fl. 89) e apresentou defesa prévia à fl. 87.

A decisão de fls. 90/92 recebeu a denúncia e deu início à fase de instrução, na qual foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Ao final, o réu foi interrogado

(fls. 132-mídia, 145/150, 151/156 e 157/165).

Superada a fase de diligências, em alegações finais o representante do Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, pois entendeu comprovadas a autoria e a materialidade delitivas (fls. 237/241).

Em outro ângulo, a Defesa preliminarmente rogou pelo reconhecimento da nulidade do processo, uma vez que as provas dos autos foram obtidas por meios ilícitos, tendo em vista a violação de domicílio. Quanto ao mérito, pugnou pela absolvição diante da ausência de provas e de elementos para corroborar um édito condenatório. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, bem como fixação de regime inicial aberto e substituição da pena corporal por restritiva de direitos (fls. 277/330).

É o relatório.
DECIDO.

De início, repilo a preliminar ventilada pela Defesa quanto à nulidade das provas sob o argumento de violação de domicílio, haja vista que, no caso concreto, os policiais receberam informação da prática criminosa pelo réu em sua residência, de modo que, no endereço, os militares foram recebidos pelo réu e este autorizou o acesso ao imóvel, onde foram localizados os estupefacientes, motivo pelo qual não há se falar em violação de domicílio.

Outrossim, apenas por amor aos debates, cabe acentuar que o delito em análise se trata de crime permanente, o qual autoriza a entrada policial no domicílio, com ou sem mandado judicial, em evidente estado de flagrância. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - TRÁFICO DE DROGAS - CRIME PERMANENTE - NULIDADE INEXISTENTE - ASSOCIAÇÃO CRIMINAL - ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO. Em razão do caráter permanente do delito de tráfico de drogas, o flagrante é possível a qualquer momento, não constituindo ilegalidade o ingresso de policiais na residência do suspeito, mesmo sem mandado de busca e apreensão, pois a regra constitucional da inviolabilidade do lar não socorre agente em situação flagrancial. [...] (TJMG. 4ª Câmara Criminal. Apelação Criminal 1.0290.18.004394-2/001. Relator: Des. Fernando Caldeira Brant. Data do julgamento: 16 de outubro de 2019) (destaquei)

Ainda, cabe ressaltar a sólida jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

[...] 7. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que, nos casos de crime permanente, não há ilegalidade na busca e apreensão por violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a entrada da autoridade policial seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial. Habeas corpus não conhecido. (STJ. Quinta Turma. HC 309.567/CE. Relator: Min. Joel Ilan Paciornik. Data do julgamento: 3 de abril de 2018)

De mais a mais, ainda a título de argumentação, nenhum direito fundamental é absoluto. O princípio da proporcionalidade deve ser levado em consideração quando houver conflito entre duas garantias constitucionais e, se observado um confronto entre a inviolabilidade domiciliar e a segurança pública, deve esta preponderar.

Por consequência, não há se falar em provas produzidas por meios ilícitos, afastando-se a preliminar arguida.

Alijando a matéria preliminar aventada, passo à análise do mérito.

Pois bem. Trata-se de ação penal pública instaurada para a apuração do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

O conjunto probatório é contundente e apto a dar arrimo à procedência da denúncia.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 3, boletim de ocorrência de fls. 7/9, auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, laudo de constatação provisória fls. 12/16, laudo toxicológico definitivo de fls. 245/248, bem como pela prova oral amealhada nos autos.

A imputação da autoria do delito ao réu é igualmente inarredável, pois foi fruto da prova colhida em Juízo, sob a égide do princípio do devido processo legal, assegurando, de forma imperiosa, o contraditório e a ampla defesa.

Em seu interrogatório, o réu disse que, na data dos fatos, estava em sua residência e foi surpreendido pelo ingresso dos policiais no imóvel, tendo sido questionado sobre a existência de arma de fogo. Aduziu ser usuário de drogas, possuía dívida com traficante e estava sendo ameaçado, razão pela qual estava armazenando as porções de entorpecentes em sua casa. Esclareceu ter sido preso posteriormente pela prática de tráfico de drogas (fls. 132-mídia e 157/165).

O policial militar Marcelo Donizete Cardoso Venturini relatou que o Copom recebeu informações anônimas no sentido de que haveria arma de fogo enterrada no terreno da casa do réu e estupefacientes, razão pela qual foi incumbido de se dirigir ao imóvel, onde encontrou o réu no portão e teve o acesso autorizado, localizando em um cômodo da residência 17 porções de crack, quantia em dinheiro, eppendorfs vazios e uma porção de maconha, quando então o réu admitiu o delito. Acrescentou que não foi encontrada arma de fogo no imóvel (fls. 132-mídia e 145/150).

No mesmo sentido, o policial Erivelto Mendes da Luz falou que recebeu notícia anônima de que o réu estava praticando o tráfico de entorpecentes, como também havia escondido uma arma de fogo em sua residência, sob uma árvore. Mencionou que foi ao imóvel e o réu autorizou o ingresso, tendo sido localizadas porções de droga na casa, momento em que o réu afirmou que há um mês estava praticando a mercancia. Contou que nenhuma arma de fogo foi encontrada. Explicou que as informações foram feitas por meio do telefone 190, tendo recebido a designação de averiguar a situação (fls. 132-mídia e 151/156).

Ao que se vê, as provas carreadas aos autos, em especial a confissão do réu e os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem e da apreensão dos entorpecentes, dão respaldo ao decreto condenatório.

As circunstâncias evidenciam a prática do delito nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar”, verbos nucleares trazidos pelo tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Como se observa, o réu confessou o crime e a prática veio corroborada por todo o restante do conjunto probatório. Aliás, deve-se destacar que a confissão ostenta elevada carga probante a tranquilizar o espírito do julgador na formação do seu convencimento, ainda mais se confirmada pelas demais provas constantes nos autos, como no caso.

Outrossim, os policiais militares foram uníssonos e categóricos em afirmar como se deram os fatos, haja vista que o Copom recebeu notícia, por meio de telefonema, da prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo pelo réu, conforme prova oral e documental (ofícios de fls. 195/196 e 206/207, boletim de ocorrência da Polícia Militar de fls. 197/203 e áudios de fl. 214), motivo pelo qual os policiais foram ao endereço, avistaram o réu no portão e dele receberam autorização

para ingressar no imóvel, onde foram localizadas quantia em dinheiro, eppendorfs vazios, uma porção de maconha e 17 pedras de crack.

A propósito, nada há nos autos capaz de retirar o valor probatório dos depoimentos dos policiais, os quais mantiveram as mesmas versões em ambas as fases do procedimento, razão pela qual merecedores de credibilidade. A essência dos depoimentos dos militares revelou-se, em sua substância, uniforme e factível em Juízo.

Com efeito, não podem ser desconsiderados os depoimentos dos agentes, servidores públicos cumpridores de seus deveres, já que foram compromissados como qualquer outra testemunha e não possuem interesse em incriminar o réu. Necessário ressaltar que a função da Polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos militares, razão pela qual não merecem ver desprestigiadas suas palavras somente pelo fato de pertencerem ao quadro da Polícia:

"Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que eles foram submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades. [...] Ressalte-se que, como é cediço, policiais não estão legalmente impedidos de depor em processos nos quais tenham participado da fase investigativa, revestindo-se suas palavras de relevante valor probatório, mormente quando prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Ademais, nada de concreto foi trazido aos autos no sentido de infirmar os seus relatos, sendo certo que não teriam razão alguma para imputar a prática de infração tão grave a pessoas que sabem ser inocentes." (TJSP. 11ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001971-89.2017.8.26.0530. Relator: Salles Abreu. Data do julgamento: 3 de outubro de 2018)

TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA.

1. Para se desconstituir o édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

(STJ. HC nº 267.025 - DF. Relator: Ministro Jorge Mussi. Data do julgamento: 02 de maio de 2013) (destaquei)

Ora, diante de toda prova produzida e com riqueza de detalhes de como se deram os fatos, não há se falar em fragilidade probatória a ponto de propiciar a absolvição do réu.

Da análise do boletim de ocorrência de fls. 7/9, do auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, do laudo de constatação provisória de fls. 12/16 e do laudo toxicológico definitivo de fls. 245/248, é possível observar que foram apreendidas uma porção de maconha (8,81 g) e 17 pedras de crack (2,19 g), além da quantia de R\$ 226,65 e eppendorfs vazios, a corroborar o exercício da traficância.

Não fosse pela prova oral produzida, já tão suficiente à condenação, a variedade, a quantidade e a forma como os produtos foram encontrados, além da quantia em dinheiro encerram circunstâncias que, analisadas em conjunto, induzem à certeza da destinação ao comércio.

Igualmente, para a consumação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, crime permanente, basta a prática da conduta do núcleo do tipo, ou seja, uma das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

É certo também que a legislação antidrogas estabelece que, para a caracterização do crime de tráfico, mister a análise da natureza da droga, sua quantidade, avaliação do local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente de drogas. A quantidade de entorpecente apreendido tem sido referencial na jurisprudência brasileira para caracterização do ilícito da mercancia. Claro que não basta essa única circunstância. Todo conjunto probatório leva à responsabilização do réu. Nesse sentido:

[...] 5. Tráfico de drogas e uso de substância entorpecente. O fato do réu não ter sido preso em atos de traficância, por si só, pouco importa, afinal, o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de um dos dezoito verbos núcleos do tipo, previstos no preceito primário do referido dispositivo legal ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas"), a Lei Especial não exigindo que o agente esteja em atos de mercancia, até porque tipifica como crime a prática das condutas acima mencionadas ainda que "gratuitamente". Precedentes do STJ [...] (TJSP. 3ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001686-11.2011.8.26.0400. Relator: Des. Airton Vieira. Data do julgamento: 10 de outubro de 2017)

Por todo o exposto, entendo que o quadro probatório formado ao longo da instrução autoriza a conclusão do cometimento, pelo réu, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Concluindo pela condenação, passo à dosimetria da pena.

De acordo com o artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade do réu não merece maior reprovação, pois ficou estrita à prática do delito. O réu não ostenta antecedentes criminais. Nada foi apurado sobre a sua conduta social e sua personalidade, assim reputo-as em seu favor. O motivo do crime é o comum: expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia. As circunstâncias e as consequências do delito não lhes são desfavoráveis.

Destarte, por inexistir circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Contudo, segundo a Súmula nº 231 do STJ, nesta fase a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, de sorte que a sanção fica mantida da forma como anteriormente fixada.

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena. Também não é possível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista a variedade e a quantidade de entorpecentes apreendidos, fato que revela a dedicação do réu a atividades delitivas, com a existência de uma estrutura voltada à prática da traficância, não se tratando de traficante eventual. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 130 PEDRAS DE CRACK. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. [...] 2. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida em poder do acusado constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à minguada do preenchimento dos requisitos legais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ. 6ª Turma. AgRg no Ag nº 1.295.751 PR. Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. Data do julgamento: 14/05/2013) (destaquei)

Ademais, cumpre enfatizar o histórico infracional (fl. 29), bem como a prova coligida aos autos demonstrou que o réu se dedicava a atividades criminosas, não se tratava de traficante de primeira viagem e estava envolvido com o tráfico de entorpecentes, haja vista que a informação prestada por terceiros foi confirmada pelos policiais, como também o réu foi novamente preso no curso deste processo, pela prática do tráfico de drogas. Dessa forma, torno definitivas as penas de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Malgrado a quantidade de pena hipoteticamente autorizasse o início do cumprimento em regime semiaberto, é preciso sempre deixar claro que se trata de delito de tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado ao crime hediondo (art. 5º, XLIII, da CF/88) e que a própria Carta Magna previu tratamento diferenciado, mais rigoroso, em razão da nocividade desse delito para o bem-estar social. Além disso, o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007, dispõe que será cumprida inicialmente em regime fechado a pena por crime de tráfico de drogas. Outrossim, embora haja decisões das Cortes Superiores concedendo tais benesses, é certo que não possuem efeito erga omnes nem vinculante, de modo que a convicção dessa magistrada está preservada no tocante à análise do caso concreto. De mais a mais, a fixação do regime fechado é imprescindível à prevenção e repressão do crime cometido, de modo a atender o princípio da suficiência da pena (artigo 59 do Estatuto Repressivo). Assim, o regime inicial será o fechado.

Por fim, nos termos do artigo 44 da Lei nº 11.343/2006, é vedada a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, além, é claro, do não atendimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR o réu EDUARDO DA SILVA SANTOS à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos para cada dia-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pena a ser cumprida em regime inicial fechado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento e comunique-se à Vara de Execuções Penais, Instituto de Identificação e Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, III, da Constituição Federal).

Comprovada a origem ilícita do dinheiro apreendido e depositado nos autos (fl. 82), decreto o perdimento da importância em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/2006. Transitada em julgado, providencie-se a transferência do numerário para a conta do FUNAD e oficie-se à SENAD (artigo 63, § 4º, da Lei de Tóxicos).

Outrossim, decreto a perda dos demais objetos apreendidos (fl. 10: recipientes

plásticos vazios), devendo ser observado o disposto nos artigos 516 e 517 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

O réu respondeu ao processo em liberdade. Além disso, não se vislumbram os requisitos autorizadores da prisão preventiva, de sorte que concedo a ele o direito de recorrer em liberdade.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Bauru, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA